

第72問

甲は、Aと共謀して、乙に対して、傷害を加えたとの公訴事実で起訴され、Aと併合審理に付された。甲は、実際は、乙に対して傷害を加えていたが、何とか無罪を勝ち取ろうと考え、友人の丙に対して、虚偽のアリバイを証言してもらうよう頼んだ。なお、乙を殴ったのは、甲のみであり、Aは、その場で甲が殴っているのを見ていたにすぎなかった。

第1回公判期日において、証人として出廷した乙は、宣誓後、「甲とAに取り囲まれて、2人から何度も殴る蹴るの暴行を受けました。」と証言した。一方、目撃者として出廷し、宣誓をした丙は、「甲は乙を殴っていましたが、Aはそれを見ているだけでした。」と証言した。

乙は、被害時の恐怖等により、すっかり2人に殴られたと信じていたため、そのように証言した。

一方、丙も、Aも乙を殴っていたと誤認していたが、Aが法廷で真摯な態度をとっていたため、Aをかばおうと思って、自己の認識とは異なる証言をしたのであった。なお、丙は、甲から虚偽のアリバイを証言するように頼まれていたものの、甲のために危険を犯す必要はないと考え、上記のように証言をしたのだった。

甲、乙及び丙の罪責について、論じなさい。なお、乙に対する傷害罪の成否については、論じる必要がない。

第1 甲の罪責

- 1 甲は、丙に虚偽のアリバイを陳述するように唆しているから、偽証罪の教唆犯（169、61 I）の成否が問題となる（**論点** 犯人が偽証を他人に教唆した場合の教唆犯の成否）。

総合 288 頁 論証 153 頁

この点について、判例は可罰説を採っている（最決昭28.10.19）から、判例の立場に従えば、甲に同罪の教唆犯が成立し得る。

- 2 もっとも、丙は甲の依頼を無視して陳述しているから、教唆の因果性に欠け、甲に同罪の教唆犯は成立しない（**論点** 共犯の因果性（幫助の因果性  司H21,I旧H7-1,H10-1,H11-1,H22-1））。

総合 128 頁 論証 50 頁

第2 乙の罪責

- 1 乙は、真実には合致していないものの、自己の記憶に従った陳述をしているところ、「虚偽の陳述」（169）の意義が問題となる（**論点** 「虚偽の陳述」（169）の意味及び故意の内容）。

総合 288 頁 論証 153 頁

- 2 この点について、判例（大判大3.4.29【百選Ⅱ120】）は、証言した内容が真実か否か明らかでなくても、証人が「其記憶ニ反シタル陳述」を行った以上は偽証罪となるとし、偽証罪は証言が真実に反することが要件となっているのではないとしており、主観説に立つと評されている。

したがって、この立場に立てば、乙には偽証罪が成立しないことになる。

第3 丙の罪責

丙は、真実には合致しているものの、自己の記憶には反する陳述をしているので、「虚偽の陳述」をしていることになる。

したがって、主観説に立つ場合には、丙には偽証罪が成立する。

答案構成

第 1 乙の罪責

- 1 乙の証言は、客観的事実には反しているが、記憶に従ったものである

↓

「虚偽の陳述」に当たるとして、偽証罪（169）は成立するか

↓

- 2 主観説

↓

- 3 あてはめ

↓

偽証罪不成立

第 2 丙の罪責

主観説

↓

あてはめ

↓

偽証罪成立

第 3 甲の罪責

- 1 偽証罪の教唆犯（61 I）の成否

↓

- 2 可罰説

↓

- 3 共犯の因果性

↓

あてはめ

↓

- 4 偽証罪の教唆犯不成立

第1 乙の罪責

1 第1回公判期日において、「証人」として出廷した乙は、「宣誓」
 2 後、自己の記憶に従い、「甲とAに取り囲まれて、2人から何度も殴る
 3 蹴るの暴行を受けました。」と証言している。

4 一方、客観的な事実としては、乙を殴ったのは甲のみであり、Aはそ
 5 の場で甲が殴っているのを見ていたにすぎなかった。

6 このように、客観的事実には反しているものの、記憶に従って陳述し
 7 ている場合、偽証罪（169条）は成立するか。「虚偽の陳述」の意義
 8 が問題となる。

9 2 この点について、客観的事実に反する陳述をすることを指すとする説
 10 がある。

11 しかし、何が真実かを判断するのは裁判所であり、証人は体験した事
 12 実を自己の記憶のままに述べなければならない。にもかかわらず、記憶
 13 に反することが陳述されると、それだけで偽証罪の保護法益たる国家の
 14 審判作用が害される抽象的危険が発生する。

15 したがって、「虚偽の陳述」とは、記憶に反する陳述を指すと解す
 16 る。

17 3 本件では、乙は、被害時の恐怖等により、すっかり2人に殴られたと
 18 信じており、記憶に反した陳述をしていない。

19 したがって、乙に偽証罪は成立しない。

第2 丙の罪責

20 丙についても、乙と同様に、偽証罪の成否が問題となる。

1

1 確かに、丙の供述は、Aが暴行を加えていないという客観的真実と合
 2 致している。

3 しかし、丙は、Aも乙を殴っていたと誤認していたが、Aが法廷で真
 4 摯な態度をとっていたため、Aをかばおうと思って、自己の認識とは異
 5 なる証言をしているのである。

6 そうだとすれば、丙の証言は記憶に反する供述といえ、「虚偽の陳
 7 述」の意義を上記のように解する以上、偽証罪は成立する。

第3 甲の罪責

8 1 甲は、丙に対し、虚偽のアリバイを証言するよう唆しているから、偽
 9 証罪の教唆犯（61条1項）の成立が考えられる。

10 2 しかし、犯人（被告人）自身は偽証罪の主体とならない。正犯として
 11 処罰されないのだとすれば、犯人自身が証人に偽証を行うように教唆し
 12 た場合においても、教唆犯として処罰されないのではないか。

13 共犯の処罰根拠は、正犯を介した間接的な法益侵害に求めるべきであ
 14 る。そうだとすれば、正犯に犯罪が成立する以上、これを教唆すれば法
 15 益侵害を引き起こしているといえることができる。しかも、犯人本人より
 16 も他人の証言の方が裁判所にとって信頼度が高いから、他人に偽証させ
 17 る方が、より国家の審判作用を害する可能性が高い。

18 加えて、犯人本人が169条の主体にならないのは、期待可能性がな
 19 いからではなく、本人は証人適格がないからにすぎず、教唆犯を成立さ
 20 せることに理論的障害があるわけでもない。

21 したがって、甲には偽証罪の教唆犯が成立し得る。

2

3 しかし、丙は自己の認識に反する証言をしているものの、その内容は甲に言われたとおりの、甲にアリバイがあったという内容ではない。また、丙は甲から虚偽のアリバイを証言するように頼まれていたものの、甲のために危険を犯す必要はないと考えている。

上記のように、共犯の処罰根拠は共犯者を通じて、間接的に法益侵害の結果又はその危険を発生させる点に求められる。そうだとすれば、何らかの形で、共犯行為と結果との因果性が要求されると解される。

本問では、丙は甲のために危険を侵す必要はないと考えて、甲の依頼とは別の内容の証言をしており、因果性は断ち切られているといえる。

4 以上より、甲には偽証罪の教唆犯は成立しない。

以上

3

4